

1500421-61.2021.8.26.0621

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Valdir Marins Alves

Comarca: Lorena

Foro: Foro de Lorena

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/07/2022

... desnecessário para a tipificação do crime de tráfico de drogas o agente ser flagrado em atos de mercancia, visto que presente uma dentre as múltiplas ações previstas no tipo penal, já é suficiente para caracterizá-lo, uma vez afirmada, tal como aqui, a finalidade mercantil dos narcóticos apreendidos.

Confira-se, nesse sentido:

"O tipo penal de tráfico é de conteúdo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lorena

Foro de Lorena - Vara Criminal

Av. Eptácio Santiago, 99, Lorena-SP - cep 12600-530

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500421-61.2021.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500421-61.2021.8.26.0621

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2107220/2021 - 2º Distrito Policial de Lorena, 17433198 - 2º Distrito Policial de

Lorena, 351/21/204 - 2º Distrito Policial de Lorena, 2107220 - 02º D.P. LORENA,

351/21/204 - 02º D.P. LORENA

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

DAVID ROBERT DA SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Valdir Marins Alves

VISTOS.

Trata-se de Ação Penal movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de DAVID ROBERT DA SILVA, qualificado nos autos, na qual lhe é atribuída a prática do crime previsto no artigo 33, "caput", combinado com artigo 40, inciso III, todos da Lei 11.343/06, pelos fatos narrados na peça inicial de fls. 124/125. Oferecida a denúncia, foi decretada a prisão preventiva do acusado (fls. 141/145), preso desde 09.12.2021 (fls. 162/165).

O réu, notificado (fl. 167), apresentou defesa prévia às fls. 171/172, por defensor dativo (fl. 168).

Não sendo caso de absolvição, a denúncia foi recebida em 28.03.2022 e designou-se audiência de instrução e julgamento, nos termos do artigo 56 da Lei 11.343/06 (fls. 175/180).

O acusado constituiu defensora à fl. 212, juntou documentos (fls. 213/229) e protestou pela oitiva de testemunha (fls. 209/2011), o que foi deferido (fl. 231).

Na audiência de instrução e julgamento foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela Acusação, assim como uma testemunha arrolada pela Defesa; após, o réu foi interrogado. Em seguida, as partes foram instadas a se manifestar nos termos do artigo 402 do Código de Processo Penal, sendo que a Acusação nada requereu; a Defesa, por seu turno, desistiu da realização do exame toxicológico antes requerido, o que foi homologado. Encerrada a instrução, o Ministério Público manifestou-se em alegações finais, pugnando, em suma, pela total procedência da incoativa, com condenação do réu nas penas cominadas ao tráfico de drogas, acrescidas da causa de aumento do inciso III do artigo 40 da Lei 11.343/006 (fls. 234/235), sendo tudo registrado em arquivo audiovisual (fl. 236). Por seu turno, a Defesa pugnou pela conversão dos debates orais em memoriais por escrito, o que foi deferido e, em alegações finais, juntadas às fls. 237/251, acompanhada de documentos de fls. 252/312, protestou pela fixação da pena base no piso, sendo ordinária a quantidade de entorpecentes apreendidos, assim como favoráveis as circunstâncias judiciais. Pugnou, ainda, pela aplicação da atenuante da confissão, assim como o afastamento da causa de aumento indicada na peça acusatória, porquanto o crime ocorreu em plena Pandemia de Covid-19 instaurada no país, além de o local estar em obras, não ser frequentado por populares e não ser, tecnicamente, uma praça; aplicação da causa de diminuição de pena do parágrafo 4º do artigo 33 da LD; fixação de regime mais brando que o fechado e a revogação da prisão preventiva, sendo o réu dependente químico crônico. Possibilitou-se, à vista do contraditório, a manifestação do "Parquet" (fl. 313), que se resumiu em parecer contrário ao pedido de revogação da preventiva (fl. 317). É o relatório.

Fundamento e Decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 03/06), auto de exibição e apreensão (fl. 07), laudo de constatação provisória (fl. 36) e, notadamente, pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 84/86), cujos resultados atestaram que a substância apreendida em poder do réu se tratava de "cocaína", substância proibida pela Portaria SVS/MS nº 344/1998 e atualizações da Portaria SPTC 136 de 03.08.2020).

A autoria, da mesma forma, é inquestionável.

Interrogado em Juízo, o réu confessou, parcialmente, os fatos que lhe foram imputados na denúncia. Confessou que, no dia dos fatos, estava de posse da cocaína e que a mesma se destinava ao vil comércio. Verberou que os dois indivíduos que estavam em sua companhia não tinham relação com o delito, sendo certo que sequer conhecia Matheus. Afirmou que o dinheiro encontrado consigo era de origem lícita, dizendo que, quando da sua prisão, ainda não tinha vendido nenhum "pino". Relatou que, no dia dos fatos, tinha feito uso abusivo de droga, sendo que estava desde às 6h naquele local. À noite, lhe ofereceram droga para vender, o que foi por ele aceito. Respondeu que tinha consciência do risco de vender droga, mas "necessitava", pois não tinha mais como "arrumar mais dinheiro". Disse que, no dia dos fatos, tinha feito uso de cocaína e também de "crack". Afirmou ser usuário de cocaína, desde os 16/17 anos de idade; e, de "crack", desde os 18 anos. Asseverou que passou por tratamento no CAPS Lorena e que nunca tinha sido internado. Relatou que começou a vender droga em abril; que já tinha feito uso de droga naquele local. Às perguntas da Defesa, respondeu que, no dia dos fatos, já tinha usado, no mínimo, 8 (oito) pedras de "crack"; que, devido ao uso abusivo de droga, seu comportamento mudou muito, dizendo que, por vezes, passava 3 (três) dias nas ruas, sem voltar para casa, sem tomar banho; que o "crack" lhe trouxe inúmeros prejuízos, como afastamento da família; que, preso há cerca de um ano e sem fazer uso de drogas, hoje consegue perceber que seu comportamento e até auto-imagem estavam profundamente degradados pelo vício, recordando-se, ainda, que até a casa em que morou pegou fogo; que pretende fazer tratamento de combate à drogadição e não quer mais "voltar para essa vida"; que seu pai também era dependente de "crack", sendo

que chegaram a fazer uso conjunto daquela droga; que depois da morte de seu pai, aumentou o consumo de "crack" (fl. 236).

A testemunha Fábio Alexandre Paschoal Silva, policial militar, ouvida em Juízo, relatou que estava em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, já conhecido nos meios policiais como sendo de reunião de usuários e traficantes de drogas, deparando-se com o réu e outros dois indivíduos, os quais, ao verem a viatura, tentaram empreender fuga, sendo detidos. Em revista aos abordados, a testemunha relatou que encontrou, em poder do réu, escondido dentro de sua bermuda, 159 microtubos (eppendorf) contendo cocaína, assim como em seu bolso, o valor de R\$ 35,00 (trinta e cinco reais) em espécie. Com os outros dois indivíduos nada de interesse policial foi encontrado, sendo que o réu lhes confessou que teria recebido o entorpecente da referida dupla. Indagada, a testemunha afirmou não ter notado sinais de que o réu estivesse sob efeito de droga quando da sua prisão, afirmando a ausência de odor de drogas, olhos vermelhos e a ponta dos dedos amarelada. O policial também respondeu que no momento do flagrante não se notava nenhum evento público no local, mas sim movimentação ordinária e, talvez, alguma reforma (fl. 236).

No mesmo sentido, depôs o seu parceiro de farda, Leandro da Silva Ribeiro.

A testemunha de defesa Marcílio Cabral, ouvida em Juízo, informou que trabalhou com o réu, em serviços de pintura e gesso, sob as ordens do mesmo empreiteiro, entre os anos de 2013 a 2016; que o colega de trabalho era empenhado com a boa função, assim como assiduidade e pontualidade. Contudo, depois dessa data, ouviu dizer que o réu se envolveu com drogas. Atualmente, a testemunha reside na cidade de Caraguatatuba e vem a Lorena apenas em visita, sendo sua última estadia nesta urbe há aproximadamente três meses. Sustentou que chegou a ver o réu após o período que trabalharam juntos, em bares e com a aparência muito debilitada em razão da droga, mas não chegou a trocar qualquer palavra com ele. Por fim, declarou que conhece a praça em que ocorreu o flagrante "a praça, acho que é a da Raia" (sic), pois está no cominho da casa da sua genitora em Lorena e não é frequentada pela comunidade (famílias e crianças), sendo conhecido como local de tráfico e uso de drogas (fl. 236).

Pois bem.

A autoria, como dito alhures, é certa.

O réu confessou a traficância, o que foi corroborado, ademais, pelo testigo dos milicianos.

Sobre isso não paira qualquer dúvida.

O réu, ao tempo da ação delitiva, tinha plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Com efeito, indagado acerca disso, respondeu, de forma bastante segura, que "tinha consciência do risco de vender droga".

De outra banda, a simples condição de usuário de drogas não é o suficiente para, por si só, afastar a imputação, pois o usuário também pode ser traficante.

Confira-se:

Autoria e materialidade demonstradas. Declarações dos policiais militares presumidamente idôneas. Desclassificação para o delito de uso próprio.

Impossibilidade. Prova acusatória demonstrativa da destinação comercial das drogas.

O fato de o agente ser também usuário de droga não obsta a condenação pelo tráfico de entorpecente. Pena e regime mantidos. A incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, não afasta o caráter hediondo da traficância. Apelo improcedente. (Apelação Criminal n. 0026892-10.2011.8.26.0050, 13ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, rel. Des. Renê Ricupero, j. 09.08.12, v.u.)

Ainda que o réu tenha dito em seu interrogatório ser usuário de entorpecentes de longa data, este também admitiu que passou a traficar para sustentar o vício e, no momento do flagrante, estava na posse das drogas ilícitas para essa específica finalidade, ou seja, a venda delas a terceiros.

Tal depoimento somado a quantidade de entorpecentes apreendidos (159 microtubos contendo cocaína), além da quantia de dinheiro em espécie (trinta e cinco reais em notas diversas), conduzem para a certeza de que a maior parte dessa droga era

destinada mesmo ao comércio ilícito.

Não é demais lembrar ser desnecessário para a tipificação do crime de tráfico de drogas o agente ser flagrado em atos de mercancia, visto que presente uma dentre as múltiplas ações previstas no tipo penal, já é suficiente para caracterizá-lo, uma vez afirmada, tal como aqui, a finalidade mercantil dos narcóticos apreendidos.

Confira-se, nesse sentido:

"O tipo penal de tráfico é de conteúdo variado ou misto alternativo, pois qualquer das condutas descritas tipifica o delito. Assim, mesmo que o agente não tenha comercializado a droga, a simples guarda é suficiente para que se configure o tráfico de entorpecentes" (TJ/RS, Apelação n.º 697.020.717, j. 30-4-1997, Rel. Des. Érico Barone Pires, RT 745/633).

"APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Recurso defensivo - Autoria e materialidade delitivas comprovadas - Prisão em flagrante e firmes depoimentos dos policiais militares - Desclassificação da conduta para a prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06 - Descabimento - Tipo penal que prevê diversas condutas - Desnecessidade da prova da efetiva mercancia - Condenação mantida - (...) Recurso não provido". (TJSP; Apelação Criminal 1500932-98.2019.8.26.0566; Relator: Roberto Porto; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 10/12/2019; Data de Registro: 12/12/2019) (Ênfase na reprodução).

Provas, portanto, materialidade e autoria, passo a dosar a reprimenda. Em consequência da análise detida da prova colhida nos autos, conclui-se que o contexto probatório é harmônico e coerente, robusto o suficiente a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório, restando incólume de dúvidas que o réu realizou conduta antijurídica, subsumível em tipo penal, e ante sua culpabilidade, impõe-se a condenação e a pena, que passo a dosar, eis que em seu benefício não militam quaisquer justificativas ou dirimentes.

Passo à fixação da pena.

Prevê o artigo 68 do Código Penal que a pena base será fixada atendendo-se ao critério do artigo 59 deste código (circunstâncias judiciais); em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes (artigo 65) e agravantes (artigos 61 e 62); por último, as causas de diminuição de pena, assinalados em quantidades fixas (dobro, metade, etc) ou em limites (um a dois terços), previstos na parte geral do Código Penal (cf. Código Penal Comentado, Celso Delmanto, 4ª edição, Renovar, p. 120).

Já o artigo 59 dispõe que o Juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime: as penas aplicáveis dentre as cominadas; a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos; o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade e a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

E, por fim, o artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 dispõe que o juiz, na fixação da pena, considerará, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Fixadas essas diretrizes, anoto que o réu é primário e portador de bons antecedentes; a quantidade de droga com ele apreendida, segundo meu interpretação, não destoa do normal à espécie delitiva, levando-se em conta, inclusive, as características da Comarca de Lorena. Sendo assim, fixo a pena base no mínimo legal, isto é, 05 anos de reclusão, e pagamento de 500 dias-multa.

Na fase intermediária, embora reconhecida a confissão, necessário apontar a impossibilidade de redução da reprimenda para alguém do mínimo legal, em respeito à Súmula 231 do STJ ("A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal").

Na derradeira etapa, não verifico a incidência da causa de aumento de pena do artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, já que "A prática de crime de tráfico de

drogas em praça pública, por si só, não atrai a incidência da majorante prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06, porquanto não prevista em lei, sendo vedado o uso da analogia in malam partem" (AgRg no AREsp n. 1.495.549/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 27/2/2020).

O réu não faz jus ao redutor previsto no parágrafo 4º do artigo 33 da LD.

Em que pese ser primário e portador de bons antecedentes, necessário apontar que o réu vem se dedicando às atividades criminosas.

Com efeito, o réu foi recentemente condenado, por idêntica conduta (tráfico de drogas), à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime aberto, nos autos do Processo nº 1500589-63.2021.8.26.0621, conforme certidão juntada às fls. 319/320, o que demonstra, de forma inequívoca, que não agiu de modo isolado, casual, mas, ao contrário, seu envolvimento habitual com a atividade criminosa. Além disso, a certidão de fls. 192/193 aponta a existência de inquéritos policiais, ainda em andamento, todos relacionados à prática do idêntico crime. Observa-se que, embora tais anotações não retirem do réu o status da primariedade e de portador de bons antecedentes, servem à caracterização de dedicação dele à atividade criminosa.

Confira-se:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI N.º 11.343/06. NÃO APLICABILIDADE. CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Inquéritos policiais e ações penais em curso, ainda que relativos a fatos posteriores aos do delito questionado, muito embora não configurem maus antecedentes e tampouco reincidência, podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido." (STJ, AgRg no HC nº 553.258/MG, Sexta Turma, Relator Ministro Nefi Cordeiro, julgado em 23.06.2020, DJe 29.06.2020)

Enfim, não é o caso de aplicar o redutor vindicado pela ilustrada Defesa, de modo que torno definitiva as penas antes fixadas em 05 anos de reclusão, e pagamento de 500 dias-multa.

Na esteira do decidido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal acerca da matéria e, ainda, o disposto no artigo 33, parágrafo 2º, alínea "b", do Código Penal, fixo o regime inicial de cumprimento da pena como sendo o semiaberto.

Considerando-se a quantidade de pena imposta, o réu não faz jus à substituição da pena privativa da liberdade por restritivas de direitos, nem tampouco à concessão de "sursis" (artigos 44, inciso I, e 77, "caput", todos do Código Penal).

Por serem parcas as informações acerca da situação financeira do réu, fixo o valor do dia multa no seu mínimo legal, a ser atualizado pelo salário mínimo da data dos fatos até o momento do seu efetivo pagamento.

Por fim, a questão da detração penal deverá ser analisada quando da execução da pena.

Nesse sentido: "Em arremate, embora não se desconheça o teor do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, não há se cogitar de sua aplicação imediata nesta seara, vale dizer, sem elementos concretos a respeito da existência (ou não) de outras condenações em desfavor do acusado, do seu comportamento no cárcere e do efetivo lapso que permaneceu preso, a recomendar a prudência e o bom senso que a questão relacionada à detração penal, assim como o pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, sejam analisados, por primeiro, pelo juízo das execuções, evitando-se supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, sem desconsiderar que o último está sujeito, ainda, à cláusula rebus sic stantibus, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil" (TJSP, Apelação Criminal nº 0000428-31.2017.8.26.0569, da Comarca de Cabreúva, 5ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Juvenal Duarte, J. 17.04.2019).

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação Penal para condenar o réu DAVID ROBERT DA SILVA, qualificado nos autos, às penas de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal, por infração ao disposto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

Estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão cautelar do réu. Com efeito, preso em flagrante pelo delito que ora é julgado, em 19/04/2021, lhe foi concedida liberdade provisória no dia seguinte (fl. 57), sendo posto em liberdade em 20/04/2021 (fl. 76), vindo a ser preso em flagrante delito, novamente por tráfico de drogas, em 20/06/2021 (fls. 187/188), permanecendo preso desde então. Deste modo, a manutenção da prisão cautelar se destina à garantia da aplicação da lei penal, consistente no cumprimento da pena ora aplicada, e, ainda, para a garantia da ordem pública, dado o fato de o réu ter demonstrado se dedicar às atividades criminosas.

Recomende-se, pois, o réu, na prisão em que se encontra. Interposto recurso desta sentença por qualquer das partes, expeça-se, de imediato, Guia de Execução Provisória.

Decreto, ainda, o perdimento da quantia apreendida com o réu em favor da União, dado ser notório que a mesma é produto de crime. Para tal conclusão, basta dizer que o réu afirmou ter dado início à venda de drogas porque era necessário para manter seu vício, denotando que esta era sua única - e ilícita - fonte de renda. Expeça-se o necessário, com o trânsito em julgado.

Com relação ao celular, também apreendido à fl. 07, nada fora produzido nos autos indicando o emprego dele no crime destes autos, ou mesmo de que era produto do mesmo. Assim, intime-se a quem de direito, que deverá apresentar prova idônea de sua propriedade, para retirá-lo.

No mais, não sendo tal aparelho reclamado, no prazo referido no artigo 123, do Código de Processo Penal, deverá ser vendido em leilão, depositando-se o saldo à disposição do juízo de ausentes, salvo se não apresentar mais conteúdo econômico. Nesse caso, após a devida certificação nos autos, fica autorizada sua destruição, observada as disposições normativas pertinentes.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta sentença, adotem-se as seguintes providências: a) Expeça-se guia de execução definitiva ou seu complemento; b) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia desta decisão, para cumprimento do disposto nos artigos 71, §2º do Código Eleitoral c/c inciso III do artigo 15 da Constituição da República; c) Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais deste Estado para as anotações necessárias; d) Oficie-se à Autoridade Policial, nos termos do artigo 72 da Lei 11.343/06, sobre a amostra guardada para contraprova; e e) Adotadas as cautelas legais, com o cadastramento dos processos de execução, arquivem-se com baixa.

Custas a cargo do réu, observada a gratuidade da Justiça que ora lhe concedo.

Sem prejuízo, providencie a zelosa Serventia, se ainda não o fez, a expedição da certidão de honorários advocatícios, conforme determinado à fl. 231.

Publique-se. Intimem-se e Cumpra-se.

Lorena, 18 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA